

<제3장 취소소송의 당사자적격.제3절 권리보호의 필요(협의의 소의 이익)>

I. 소의 이익의 의의

1. 개념

- 소의 이익이라 함은 원고가 취소소송을 통해 본안 판결을 받아 자신이 주장하는 권리 또는 법률상 이익을 구제받을 필요성을 말한다. 이는 원고적격이 소송 제기 당시 법률상 이익의 침해 가능성에 주안점을 두는 데 비하여, 소의 이익은 소송이 계속되는 동안 판결을 받을 실효성과 계속적인 법률상 이익의 존재 필요성을 의미한다. 협의의 소의 이익은 소송의 종료 시점까지 원고의 권리 구제에 실질적인 도움이 되는지 여부로 판단된다.

2. 법적 근거

- 소의 이익의 법적 근거는 행정소송법 제12조 후문에 있다. 동 조항은 처분등의 효과가 기간의 경과, 처분등의 집행 그 밖의 사유로 인하여 소멸된 뒤에도 그 처분등의 취소로 인하여 회복되는 법률상 이익이 있는 자의 경우에는 또한 같다.고 규정한다. 이 규정은 원칙적으로 소멸된 처분에 대한 소의 이익을 부정하지만, 예외적으로 회복되는 법률상 이익이 있는 경우에는 소의 이익을 인정함으로써 소의 이익의 범위 확장 근거를 마련한다.

3. 행정소송법 제12조 후문의 법적 성질

- 행정소송법 제12조 후문은 소의 이익의 존부를 판단하는 기준 규정으로서, 취소소송의 소송요건을 구성하는 규정이다. 이 규정은 취소소송의 가치가 단순히 원처분의 효력 제거에 국한되는 것이 아니라, 나아가 위법 상태의 재발 방지나 가중된 불이익 배제 등 다른 법률상 이익의 회복 필요성까지 포함함을 명확히 한다. 소의 이익이 결여되면 법원은 직권으로 조사하여 본안 판단을 거부하고 각하판결을 내려야 한다.

4. 회복되는 법률상 이익의 범위

- 행정소송법 제12조 후문에서 말하는 회복되는 법률상 이익은 취소 판결의 결과로 원고에게 돌아가는 이익을 의미한다. 이 이익은 단순히 사실상 이익이나 감정적 만족을 넘어 법적으로 보호되는 가치를 가져야 한다. 구체적으로 이는 ① 가중된 불이익 제거 가능성, ② 후속 처분의 적법 요건 확보 가능성, ③ 명예나 신용 등 법률상 보호되는 무형의 이익 회복 가능성 등을 포함한다. 이러한 이익이 존재하는 경우에만 처분의 효력이 소멸했더라도 소의 이익이 인정될 수 있다.

II. 소의 이익의 일반적 판단기준

1. 판단기준[행소법 제12조 후문]

- 소의 이익은 원칙적으로 처분의 취소를 통해 원상회복이 가능하거나 침해된 법률상 이익이 회복될 실질적인 가능성이 있어야 인정된다. 판단의 기준 시점은 사실심 변론종결 시이다. 행정소송법 제12조 후문의 취지에 따라, 설령 처분의 효력이 소멸했다 하더라도, 취소 판결의 기속력을 통해 장래의 가중된 불이익을 방지할 수 있거나, 기타 법률상 이익을 회복할 수 있다면 소의 이익은 인정된다. 따라서 판단은 형식적인 처분 효력 유무가 아닌 실질적인 법률상 이익의 회복 가능성에 초점을 맞춘다.

2. 소의 이익의 범위 확장

- 소의 이익의 범위 확장은 주관적인 권리 구제 외에 객관적인 행정의 적법성 확보 및 법질서의 유지라는 공익적 목적을 고려하여 이루어진다. 특히 ① 반복될 위험성이 있는 유사 위법 처분에 대해 취소 판결의 기속력을 미치게 함으로써 장래의 침해를 예방하는 경우, ② 당해 처분의 취소가 다른 법률관계의 선결 문제가 되어 원고의 법적 지위에 영향을 미치는 경우에 소의 이익이 인정되어 그 범위가 확장된다. 이러한 확장은 법원의 재량적 판단 영역이 아니라 행정소송법 제12조 후문의 취지에 따른 법률상 이익의 인정 문제로 파악된다.

III. 소의 이익 인정 여부의 유형별 검토

1. 처분의 효력이 소멸한 경우

- 처분의 효력이 기간의 경과 등으로 소멸한 경우, 원칙적으로 처분을 취소하더라도 원상회복이 불가능하므로 소의 이익이 부정된다. 예를 들어 단기 간의 영업 정지 기간이 만료된 경우 등이다. 다만, 소멸된 처분이 장래의 법률 관계에 영향을 미쳐 원고에게 불이익을 초래할 때는 예외적으로 소의 이익이 인정된다. 가장 대표적인 예는 선행 처분이 가중된 제재 처분의 전제 조건이 되는 경우이다. 이때 취소 판결을 통해 가중 제재를 면할 수 있는 법률상 이익이 회복되는 것으로 본다.

2. 처분 후의 사정변경에 의하여 권리침해상태가 해소된 경우

- 처분이 있은 후 원고의 사망, 목적물의 멸실, 양도 등 사실상의 사정 변경으로 인해 침해된 권리 상태가 해소된 경우, 더 이상 취소 판결을 구할 실익이 없으므로 소의 이익이 부정된다. 예를 들어 운전면허 취소 처분 후 원고가 사망한 경우 등이다. 다만, 사정변경이 단순한 사실상의 해소에 그치지 않고 다른 법률상의 이익 회복 필요성을 남기는 경우에는 소의 이익이 인정될 수 있다. 예를 들어 징계 처분 후 퇴직하였더라도 퇴직금 등 법률상의 권리에 영향을 미치는 경우 등이다.

3. 원상회복이 불가능한 경우

- 처분의 취소를 신고하더라도 이미 원상회복이 물리적 또는 법적으로 불가능하게 된 경우 소의 이익은 부정된다. 예를 들어 토지 수용 처분 후 이미 공사가 완료되어 원상회복이 극히 곤란한 경우 등이다. 그러나 원상회복이 불가능하다 하더라도, 처분의 취소 판결이 국가배상청구 등 다른 구제 절차의 선결 요건이 되거나, 원고의 명예나 신용 등 무형의 법률상 이익 회복에 실질적인 도움이 되는 경우에는 예외적으로 소의 이익이 인정된다.

4. 보다 실효적인 권리구제절차가 있는 경우

- 원고에게 취소소송 외에 민사소송이나 헌법소원 등 보다 간이하고 실효적인 권리 구제 절차가 별도로 있는 경우 취소소송의 소의 이익은 부정될 수 있다. 다만, 행정소송법상 취소소송은 다른 구제 절차와 독립적으로 인정되는 것이 원칙이다. 따라서 취소소송의 판결이 장래의 법률 관계나 다른 법률상의 이익 회복에 필수적이거나 중요한 영향을 미치는 경우에는, 손해배상청구 등 다른 구제 수단이 있더라도 소의 이익은 인정된다. 예를 들어 부당이득 반환 청구를 위해 선행 처분의 취소가 필요한 경우 등이다.

5. 위법한 처분의 반복가능성이 있는 경우

- 단기적 처분의 효력이 소멸했더라도 동일한 상황에서 유사한 위법 처분이 반복될 위험성이 높아 취소 판결의 기속력을 통해 장래의 침해를 예방할 필요성이 있는 경우에는 소의 이익이 인정된다. 이는 단기 처분의 특성상 소송 도중 효력이 만료되어 국민의 재판 받을 권리가 형해화되는 것을 방지하기 위함이다. 판례는 운전면허 정지 처분등 반복적이고 단기적인 제재 처분의 경우에 이를 인정하는 경향을 보인다.

6. 단계적 행정결정의 경우

- 선행처분과 후행처분이 단계적인 일련의 절차로 연속하여 행하여져 후행처분이 선행처분의 적법함을 전제로 이루어짐에 따라, 선행처분의 하자가 후행처분에 승계된다고 볼 수 있어 이미 소를 제기하여 다투고 있는 선행처분의 위법성을 확인하여 줄 필요가 있는 경우 등에는 행정의 적법성 확보와 그에 대한 사법통제, 국민의 권리구제의 확대 등의 측면에서 여전히 그 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

7. 원고의 청구가 이론적 의미만 있을 뿐 실제적 효용이 없는 경우

- 원고의 청구가 단순히 법적인 의미 확인이나 위법 선언이라는 추상적 목적만을 가질 뿐, 구체적인 법률상 이익의 회복 가능성이 없는 경우에는 소의 이익이 부정된다. 예를 들어 이미 완전히 해소된 법적 분쟁에 대하여 단순히 역사적 사실 확인을 구하는 경우 등이다. 취소소송은 주관적 소송으로서 개인의 권리 구제를 목표로 하므로, 객관적 소송의 성격을 띄는 순수한 이론적 주장만으로는 소의 이익을 인정할 수 없다.

IV. 결론

- 협의의 소의 이익은 취소소송의 원고격 확보 이후에도 소송 계속의 정당성을 유지하는 핵심적인 소송요건이다. 행정소송법 제12조 후문의 규정에 따라, 설령 기간의 경과 등으로 처분의 효력이 소멸하거나 사정변경으로 인해 원상회복이 불가능해졌더라도, 취소 판결의 기속력을 통해 장래의 가중된 불이익을 배제하거나 다른 법률상 이익을 회복할 수 있는 실질적 필요성이 존재한다면 소의 이익은 예외적으로 인정된다. 특히 단기 처분의 반복 위험성에 대한 판례의 입장은 국민의 재판 받을 권리를 실질적으로 보장하기 위한 적극적인 해석 결과이다. 따라서 소의 이익 판단 시에는 취소 판결이 원고의 법적 지위 회복에 미치는 구체적이고 실효적인 법률상의 영향을 종합적으로 고려해야 한다.